

浅析“明股实债”的主要风险及其防控

陈 帅
(华东政法大学, 上海 200333)

摘 要 近日,“新华信托”诉“港城置业”败诉一案在证券业引起热议,“明股实债”现象也被推上了风口浪尖。为了监管机构合规要求而设置的股权投资+债权回款模式违背了基本的法律逻辑。从“新华信托”提起的两起“明股实债”诉讼为起点,分析了不同判决结果的依据与原因。梳理“明股实债”现象的起因、类型、操作模式、主要风险,提出对于此创新金融产品的风险防控建议,总结肯定混合资本工具创新的意义和作用。

关键词 明股实债; 明债实股; 混合资本工具; 金融创新

一、案情述评

(一) 案例一

2016年8月,经湖州市吴兴区人民法院一审判决,原告“新华信托”股份有限公司(以下简称新华信托)与被告湖州港城置业有限公司(以下简称港城置业)破产债权确认纠纷一案,大概情况如下:

2011年6月21日,原告新华信托与被告湖州港城置业有限公司、纪阿生、丁林德签订了《湖州凯旋国际社区股权投资集合资金信托计划合作协议》,协议约定新华信托以“股权投资”的形式,向港城置业提供不超过2.5亿元信托资金,其中部分资金用于收购港城置业80%股权。该笔融资的分部分设置固定期限1.5年、2年、2.5年。但是截至信托计划到期日,被告未依约清偿信托本金及收益。

增信措施如下:一是港城置业提供土地抵押担保;二是纪阿生、丁林德以其持有的股权作为质押担保;三是纪阿生提供连带责任担保。

本案的争议焦点是新华信托向港城置业汇付的22 478万元是股权转让款还是借款。其中,新华信托认为,双方建立的是债券债务融资法律关系,虽然双方约定名义上以股权方式融资,但提前设置了固定期限和固定收益的特殊条款,应当被认定为债权。

而被告则认为是股权转让款的性质,理由如下:一是系列协议约定明确该14 400万元属于股权转让款;系列协议的履行从未就此股权转让合意作出任何变更;按照合作协议及其附属的股权转让协议均约定,新华信托也依约向港城置业指派了2名董事,参与表决,且对公司重大事项享有一票否决权。二是新华信托支付的8 078万元性质属资本公积金;三是原告主张前述22 478万元资金属于向港城置业借款的理由均背离客观事实和法律评价,也无证据证明。综上,原告关于其对港城置业享有借款债权的说法是不成立的。主债权不成立,担保债权也无从成立。因此,原告主张其对港城置业享有优先债权的说法不成立。

最终一审判决结果是,法院驳回原告新华信托股份有限公司的诉讼请求。理由主要如下:其一,破产程序中,法院倾向对第三人的信赖利益进行保护。在名实股东的问题上要区分内部关系和外部关系,对内部关系产生的股权权益争议纠纷,可以当事人之间的约定为依据,或是隐名股东,或是名股实债;而对外部关系上不适用内部约定,按照《中华人民共和国公司法》第三十二条第三款“公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记,登记事项发生变更的,应当办理变更登记,未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人”之规定,第三人不受当事人之间的内部约定约束,而是以当事人之间对外的公示为信赖依据。其二,交易结构设置不当,将导致投资性质的截然不同。如果新华信托本意是向港城置业出借款项的,港城置业从股东会决议来看亦是有向新华信托借款意向的,双方完全可以达成借款合同,并确保借款的安全性,新华信托可以要求依法办理股权质押、土地使用权抵押、股东提供担保等法律规定的担保手续。如原告在凯旋国际项目上不能进行信托融资的,则应依照规定停止融资行为。新华信托作为一个有资质的信托投资机构,应对此所产生的法律后果有清晰的认识,故新华信托提出的“名股实债”、“让与担保”等主张,与本案事实并不相符,其要求在破产程序中获得债权人资格并行使相关优先权利并无现行法上的依据,故本院对其主张依法不予采纳。

通过法院判决理由可以看出,新华信托之所以败诉,主要原因在于牵涉破产债权的第三方信赖利益保护,如果不涉及第三方信赖利益的话,仅仅是新华信托诉请偿付债务的话结果恐怕不一定会败诉。

(二) 案例二

相似案件中的“新华信托”诉“宁波强人置业公司”案。2013年5月3日,叶罕嗣、叶忠真与新华信托公司签订《信托融资合同》。同日,叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司与新华信托公司签订《股权收益权转让合同》。上述两份合同主要约定:为支持罗马假日国际大酒店内部装修工程,新华信托公司以设立集合资金信托计划的方式募集信托资金1.6亿元;新华信托公司受让叶罕嗣、叶忠真持有的强人置业公司100%股权收益权并将信托资金划付至监管账户;股权收益权转让期限2年,自前述信托计划成立生效之日起计算;叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司均负有按约履行收益权回购、支付回购款本金及溢价款的义务。叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司若未按合同约定用途使用信托资金,新华信托公司有权提前收回部分或全部资

金,并根据违约使用天数按日4%计收利息,对未支付的回购溢价款计收复利;未按约支付收益权回购款的,新华信托公司有权要求限期清偿,并可宣布全部债权进入处置期,并要求叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司另行按3%综合融资利率支付损失补偿款。其后,新华信托公司又分别与叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司签订《抵押合同》、《股权质押合同》来对上述进行担保。后因强人置业公司未按期支付相关费用,信托资金亦未完全用于《信托融资合同》约定的目的,新华信托公司向法院提起诉讼,提请判令叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司支付回购款本金、溢价款、处置期损失补偿费、复利等并对抵押物、质押权利优先受偿。

法院判决结果是:根据各合同实际内容认定为借款合同。除合同中约定的利率超过中国人民银行关于人民币贷款利率规定的部分不受法律保护外,其余内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应属有效。叶罕嗣、叶忠真及强人置业公司应按合同约定履行相应支付和担保义务。

(三) 案例要点总结

“名股实债”是实践操作中被经常采用的一种投资形式。此类“名股实债”的交易模式通过系列文件的签署,将债权包装成股权,模糊了股权与债权的界限,因此,在认定此类交易的性质时,通常会产生较大争议。虽然,最高人民法院、重庆市高级人民法院在类似的相关判例支持原告,本案还可上诉。但是,本案特殊之处在于借款人破产清算了,客观上导致原告主张权利时需要面对所谓“外部债权人”。和“外部债权人”相比,原告作为对外公告了的公司股东,无疑是先外后内。

由于目前对于“明股实债”法律法规尚无明确定义,因此也未有专门配套的监管措施,司法裁判的判例和具体依据也不尽相同。这是目前中国金融市场快速发展与法律制度建设不完善的矛盾结果。

二、“明股实债”的由来与现实

(一) “明股实债”的产生

基于对股权投资的权益性以及债权投资的稳定回报的追求,“明股实债”的投资模式作为一种创新投资业务被许多企业大量运用,其是投资方、融资方以及管理人各方利益诉求的集中体现。首先,在“明股实债”的投资模式中,融资方一方面可以满足自身融资需求,另一方面可以在账目上扩大自身的股本金,不占用授信额度。同时,此投资模式也可以有效降低资产负债比;其次,投资方一方面可以规避自身不存在放贷资质的法律规定,另一方面可以在较低风险前提下获得相应收益;最后,资产管理公

司（包括但不限于信托公司、券商资管计划等）在“明股实债”投资模式中起到非常重要的通道作用，同时，资产管理公司可以在这种交易模式中进一步扩大管理规模获取相应的管理报酬。由此可知，“明股实债”的投资模式之所以可以实现，是各方利益诉求博弈的结果。

（二）我国“明股实债”产品特征

1、股权投资形式的债务融资。信托虽是入股目标公司，但既非战略投资，也非财务投资，不以控制目标公司为目的，约定期限届满，信托有权利也有义务将股权按约定价格出售给未来购买方。除收回投资本金外，信托还能获取恒定的溢价。该溢价可看作购买方支付的资金成本。因此，该业务形式为股权融资，实质为债务融资。

2、融资主体与偿债主体非同一性，但存在明显关联关系。融资主体为目标公司，偿债主体为融资主体的股东或实际控制人。这与传统间接融资中融资主体与偿债主体同一性的特点明显有别。如平安信托入股葛洲坝房地产公司的股权约定由其股东葛洲坝集团回购。而且，投资协议中也可以通过约定由融资主体的股东溢价回购的方式来获取“利息”。

3、一般为中长期融资。融资期限为信托资金到达目标公司验资账户之日起至购买方应付购买价款之日止的期限，从现有案例看，资本金融资的期限一般为一年以上的中长期融资。

4、融资溢价率与人民币同档次贷款基准利率挂钩。购买方支付融资溢价款的方式与贷款利息计息、结息一样。融资溢价作为购买方的资金成本，其溢价率也与贷款利率相似，一般以人行公布的与融资期限同档次的贷款基准利率为基准上下浮动。

5、投资期限内，不参与融资主体的经营管理和分红，介入重大事项决策为例外。一般而言，明股实债协议中会提到“投资期限内，投资方不参与被投资企业的经营管理和分红”，由于投资方不熟悉融资企业的具体业务，一般不会参与到融资主体的日常经营和管理和股利分配中，但不排除介入重大事项决策。如新华信托对港城置业委派两名董事，并对重大决策拥有一票否决权

（三）“明股实债”的规模与资金走向概况

预计2016年末为止，“明股实债”类资产规模约2万亿，较年初增长25%—30%。展望明后两年，预计仍将维持40%—50%的较快增长。

目前银行理财、集合信托以及保险公司是明股实债类投资的主要参与主体。按照投资额度计算，截至2016年末预计银行理财占比45%—55%，集合信托占比40%—

50%，保险公司占比0—10%。

基础产业、工商企业和房地产成为“明股实债”类资产主要投资方向。预计基础产业占比55%—65%，工商企业占比25%—35%，房地产占比20%—25%。其中，基础产业主要包括交运仓储、电力水热等供应、水利环境以及公共服务等。

三、“明股实债”的主要风险及识别

（一）“明股实债”的主要风险

1、法律风险。“明股实债”是介于“股权投资”与“债权投资”之间一种模糊的状态，其法律地位尚不明晰。因此，在司法实践中，“明股实债”如被认定为股权投资，（新华信托诉港城置业案中），则投资人不能主张还本付息，得不到定期收益；如果其被认定为借贷（如新华信托诉强人置业案中），但因约定的收益未被作为利息处理，以约定不明为由适用同期银行贷款利率或者存款利率（通常是有过错的情形下）；即使收益被作为利息处理，但是超过法定利率，超过部分被认定为无效，得不到预期收益。再加上标的公司或借款人的不同经营状态以及涉及其他第三方与否，对于权益的实现都增加了不可确定的风险。另外，由于明股实债类融资工具的形式非标准化、发行方式私募化，债务性质缘起于双方回购或转让合同等具体约定，产品信用风险识别需要着重识别两个方面：一是合同对债务约定的全面性和严密性，应将合同界定的远期回购或差补债务与其主体的普通债务相比较；二是从项目的经济价值、社会价值及极端不利情景下的救助价值，考察项目自身经营的可持续性与合作外部支持的力度。总之，投资方要避免回购主体没有出现信用风险，但因合同条款约定不合法而导致无法实现回购或差补的支付等不利情况。

2、信用风险。在回购合同中，承诺未来履行受让股权义务的一方为明股实债结构中主要的信用主体，其信用风险表现为如约履行回购义务、向对方指定账户支付回购款的能力和意愿，对其信用风险评估需要考量经营能力、财务实力及其在集团或所在体系中的战略重要性。在回购主体信用质量并不是很强的情形下，可能增加差补方进行信用增进，承诺对回购进行担保或对本息款项差额进行补足，这就需要增加对差补主体的信用分析。回购人和差补人在非公开市场出具回购或差额补足承诺构成隐性债务，但其信息披露的可获得性不强，一定程度上构成主体信用分析的阻碍因素。在“明股实债”的几种实际操作模式中，投资人的权益往往没有设置相应资产的抵押、质押作为担保。其中产业基金借道PPP对被投资企业要求的增信

措施通常包括被投资公司母公司的担保或地方政府的担保。而抵押物多为项目本身或者企业实际控制人提供连带责任担保,但是由于目前我国企业及个人信用体系尚未完善,信用信息的可信度与覆盖完整程度较低。因此,一旦出现经营失衡等困难,很多企业会尽可能逃避债务,投资人即成为无辜受害者。

3、收益风险。“明股实债”模式存在的收益风险。

一是在合同性质被认定为借贷性质后,投资人的预期收益无法实现,其高于银行同期利率的部分不能得到法院支持,例如宁波强人置业的案件中,法院判决结果虽然根据各合同实际内容认定为借款合同。但是合同中约定的利率超过中国人民银行关于人民币贷款利率规定的部分不受法律保护;二是在标的公司进入到破产清算程序时,股权投资是要劣后于债权进行受偿,投资人需要承受股权本身所带来的风险,例如新华信托诉港城置业由于涉及第三人的信赖利益保护而被认定为股权性质,主债权与担保债权均无效。另外,需要特别提出的是,在明股实债类融资工具应用广泛的基础设施行业项目建设融资中,又涉及地方政府融资平台主体信用与政府的隐性支持因素。就目前阶段而言,承担基础设施项目建设的城投主体总体信用质量较高,尤其是在一二线城市,其基础设施在城市化进程和都市圈建设中具有需求增长潜力,甚至目前还处于供不应求的状态。相比之下,有些城市(如边远城市或新建园区)由于人口流出或人气不足导致城市基础设施得不到充分消化已呈过剩态势,其平台债务质量堪忧。

(二) 风险识别

在信用风险识别方面,值得一提的是,2016年一季度,信用违约事件频发导致一些债市的传统观念(诸如央企预期不违约)被颠覆。城投平台的行业信用质量普遍优于产业类,但是不同地区、不同层次、不同业务定位的城投平台之间信用质量差异其实很大,同一平台发行的不同债务信用质量也有所不同,如果不加细分,可能形成风险认知上的误区。对于城投类主体而言,主要风险在于基础设施建设行业增长的周期性放缓,地区人口流出过快和土地出让进度不达预期,地方财政对代建项目采购或回购的现金流缺口太大等,如果叠加地方低效建设形成基础设施建设项目过剩等风险因素,可能触发地区性违约事件。

四、“明股实债”的风险防控建议

(一) 格外注意PPP项目及地方政府融资项目

在项目选择上,应格外注意PPP项目以及地方政府融资平台项目。由于根据相关规定,“要坚决杜绝各种非理性担保或承诺、过高补贴或定价,避免通过固定回报承

诺、明股实债等方式进行变相融资”,因此在对于“固定回报”和“明股实债”的边界界定不明晰的情况下,项目选择上要慎重考虑。至于地方政府融资若是对“明股实债”的一概封杀,必将在很大程度上堵塞财务投资人进入PPP项目的通道,财政部和发改委的本意是否如此仍待斟酌。另外,2016年10月初,贵州省多地财政局发出声明,要求撤回已发出的承诺函。此类承诺函主要用于地方城投公司向金融机构融资担保增信机制。此类难以预测的政策变化使得融资项目选择是对于属于地方政府融资平台名单内的发行人公司的融资方案不得不格外谨慎。

(二) 设计协调一致,避免利益冲突

在“明股实债”存在的法律风险部分已经指出,合同之所以无效的前提是投融资双方未达成一致而选择司法程序的后果,因此,在结构设计上要双方协调一致,避免之后的利益冲突。在最初签订合同的磋商阶段,可以明确日后债权主张实现的各种方式,除了规定按时还款(回购)等条款之外,还应当对诉讼或仲裁路径下的权益主张与实现也提前约定相关条款。同时约定进入破产清算程序时,协议项下未履行义务与公司其余普通债权的优先次序,同时将合同协议在公司官网、监管平台或其他指定网站等公示公告,已提醒其他债权人,避免信赖利益冲突。另外,由于回购主体和差补主体多属集团公司,经营结构层级多、业务板块跨行业、债务属性多元化、信息披露欠透明,风险识别面临挑战,需在集团整体信用分析框架下强化对回购主体、差补主体的风险识别,综合考量集团融资结构,关注集团自我约束能力,或该地区财政、国资等部门对集团负债的约束机制,坚持集团风险总体可控的底线原则,事前在合同操作环节做实风控条款的设立。

(三) 减少因资金滥用导致的纠纷

投资方可以通过委派董事等方式参与标的公司的管理,从而加强监管,减少因资金滥用所导致的纠纷。虽然说以新华信托为代表的金融机构对“明股实债”类的金融产品的定位主要是固定收益类产品,并不是旨在管理控制公司的股权投资。但是既然合同约定了相关条款,可以委派董事等职位人员参与公司治理,这也是对债权人利益保护的一种措施,加强日常经营过程的监管对于债权的实现也是有利无害。投资方可能考虑固定期限较短,委派董事成本过高等原因而不愿行使此类股权类权力。笔者认为,这其中的成本收益权衡考虑对不同的标的公司、不同程度的利益大小以及合同协议的具体规定,都要以投融资双方协商一致为最终结果。但是考虑到此类产品的特殊性,一部分股权权力的条款外壳不可或缺。至于具体应当包括哪

些股权类权力以及具体的行使方式的条款安排则要看具体问题具体考虑。

(四) 确定恰当的条款和恰当的回购义务人

回购主体往往是项目的实际控制人或其指定公司,若指定公司信用质量不高,则再增加更强主体的差额补足以增信。即使差额补足主体信用等级高,但其义务履行的前提条件是回购方已经启动有效回购但回购支付的金额不足,并不等同于连带担保。因此,回购主体必须适当,回购行为应合理法,以不触发他方权利人的抗辩,杜绝法律隐患,才能保障后续的差额补足增信措施的有效落实。在新华信托诉港城置业案件中,协议约定的回购义务人是港城置业公司。法院判决被告港城置业管理人在破产程序中履行管理职权,确认新华信托对破产企业不享有破产债权是正确的。基于新华信托在港城置业中的股东身份,其出资并获得股东资格后不应再享有对破产企业的破产债权。同时由于主债权不成立,则港城置业提供土地抵押担保、纪阿生与丁林德以其持有的股权作为质押担保以及纪阿生提供连带责任担保的三项担保债权也无从成立。倘若合同约定回购义务人是纪阿生与丁林德,同时约定港城置业提供土地抵押担保、纪阿生与丁林德以其持有的股权作为质押担保等担保条款,则即使港城置业已经进入破产清算程序并不影响“新华信托”对纪阿生与丁林德主张要求履行协议约定的回购义务,同时港城置业的土地抵押等担保也不会列在破产清算财产之中。

(五) 增加其他的增信措施

除了上述增信机制之外,投资方还可视需求而定与融资方约定寻找第三方专业担保公司提供担保。或者在合同中约定该协议的权益优先于其他债权,其效果类似于约定了回购条款的优先股。在投资回购合同中约定承诺远期回购义务的回购方如果在回购期限尚未届满时破产,明股实债投资者作为权利人能否向回购主体主张破产财产分配的权利,以及即使主张但能否获得破产管理人认可,这些尚不具备充分的理论和案例支持。在回购期限尚未届满时,权利人与义务人之间的债权债务关系尚未成立,似不可向破产程序中的回购主体主张债权。但依据《企业破产法》精神,未到期的债权在破产申请受理时视为已到期,附期限的债权,债权人也可以申报,不过存在申报不被破产管理人认可的可能,相应损失的司法界定存在障碍,这将造成明股实债类金融资产的增信灭失,导致信用损失。针对差额补足主体破产情形,《企业破产法》规定将其未到期之保证责任视为已到期提前予以清偿。但对于负补充责任保证人的追偿,还存在先诉抗辩权的处理问题。为保

障交易公平、实现权利设置之本意,取消保证人的先诉抗辩权,则债权人可先行从保证人处获得清偿,但应先行提存,待债务到期债权人从债务人处行使受偿权利后,再确定保证人应承担保证责任,并按保证人实际应承担补充责任的范围向债权人支付,余款由法院收回分配给保证人的其他破产债权人。但从法律实务来看,由于差补债务在差补方破产时尚未形成,且差补债务额度难以界定,因此差补债权人的主张存在不被破产管理人受理的可能,此时差补条款的增信机制灭失。

总而言之,“明股实债”之本质仍是债权,即使设置了部分股权的条款,也只是为了更好的维护债权的实现,确保固定期限的固定收益。监管机构应按实质重于形式的基本原则对待此类金融产品。至于牵涉到第三方信赖利益与公司法中股东认定等问题,完全可以在协议中提前设置条款规定,并及时公示公告,保证信息披露以避免各种纠纷的产生。

参考文献

- [1]马涛.金融负债和权益工具区分问题研究[D].财政部财政科学研究所,2014.
- [2]何娇.永续债业务开展的动因及风险分析[D].暨南大学,2014.
- [3]高倩.永续债融资财务效果比较分析[D].杭州电子科技大学,2015.
- [4]上官鸣,周唯,白猛猛.基于永续债视角的恒大地产财报分析——以恒大地产2013年年报为例[J].财会月刊,2015(4).
- [5]臧蓉.永续债能确认为权益工具吗?——基于武汉地铁与国电电力永续债发行的案例分析[J].现代商业,2015(8).
- [6]裴悦.金融负债与权益工具的划分问题研究[D].东北财经大学,2016.
- [7]http://www.mof.gov.cn/mofhome/shandong/lanmudaohang/dcyj/201408/t20140821_1129564.html
- [8]<http://trust.jrj.com.cn/2016/11/22074921736595.shtm>

作者简介

陈帅,现为华东政法大学研教院在读硕士研究生。

责任编辑:牛源